

1500218-23.2022.8.26.0538

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME MARTINS DAMINI

Comarca: Santa Cruz das Palmeiras

Foro: Foro de Santa Cruz das Palmeiras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Além disso, houve denúncia anônima de tráfico, o indivíduo não aparentava estar drogado como um mero usuário ali presente, até porque nenhum objeto para consumo foi achado, presenciou-se as transações a compradores e o local da ocorrência é palco frequente de tráfico. Tudo isso reflete o propósito de difusão ilícita, o qual não é excluído, por si só, pela eventual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Cruz das Palmeiras

Vara Única

Avenida do Café, nº 665, Centro, Santa Cruz Das Palmeiras - 13650-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo nº:

1500218-23.2022.8.26.0538

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2107167/2022, 24408935, 2107167

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL FIRMINO BRITO

Ao(s) 09 de agosto de 2022, às 15 horas e 30 minutos, nesta cidade e Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, sendo realizada, por meio virtual, via videoconferência criada no software Microsoft Teams, sob a presidência do(a) MM(a). Juiz(a) de Direito, Dr(a). GUILHERME MARTINS DAMINI, comigo, Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, estiveram presentes na teleaudiência:

O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). SERGIO HENRIQUE MARINO, DD(a). Promotor(a) de Justiça; A(O)(s) ré(u)(s) GABRIEL FIRMINO BRITO, acompanhado(a)(s) de seu(s) Defensor(es)(a)(s) constituído(a)(s) Dr(es)(a)(s). Eduardo Rodrigues Azevedo OAB 169779/SP;

Ausente(s) na teleaudiência:

A(s) testemunha(s) de defesa Rosana Ferreira.

Após, antes do início dos trabalhos, o(a)(s) advogado(a)(s) de Defesa não solicitou(ram) comunicação privada com a(o)(s) ré(u)(s), em virtude de ter havido conversa prévia em lugar diverso e/ou ausência da(o)(s) ré(u)(s) na audiência virtual. Pelo Ministério Público, nada foi requerido.

Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM(a). Juiz foi dito: "Nos termos da resolução 465 de 2022, do Conselho Nacional de Justiça, zelando pela adequada identificação e vestimenta que a solenidade requer, alerta ao(a)(s) Advogado(a)(s) e o(s) membro(s) da Defensoria Pública e do Ministério Público da necessidade de utilização de terno ou toga, permanecendo com a câmera ligada, em condições satisfatórias e em local adequado durante toda sessão. Sem prejuízo, dispensei a oitiva da testemunha Rosana Ferreira, cujo depoimento somente poderia ser colhido a título de prova judicial de ofício, cuja conveniência em produzir fica ao exclusivo critério deste magistrado, o destinatário final da prova. Ora, a Defesa não arrolou quaisquer testemunhas quando da apresentação da defesa prévia, único momento em que poderia tê-lo feito (art. 396-A, CPP). Assim, em razão da preclusão consumativa, o "aditamento" de fls. 106/107 não comporta conhecimento. A jurisprudência respalda o entendimento: STJ, AgRg no RHC n. 166.837/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022. Ademais, aquela não se fez presente em duas audiências, o que denota a concreta impossibilidade de que seja ouvida. Ressalto, por fim, que Gustavo Ferreira da Silva foi, ao fim e ao cabo, foi inquirido como testemunha do juízo, a denotar a uniformidade no tratamento da questão. No mais, reitero aqui os fundamentos apresentados oralmente na presente audiência quanto ao ponto. ".

Ao final, pelas partes, foi dito que não haviam requerimentos de diligências a serem apresentados e/ou provas a serem produzidas. Sendo assim, deliberou o(a) MM(a). Juiz(a): "Vistos. Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução e determino às partes que apresentem suas alegações finais.". Dada a palavra ao Ministério Público e a Defesa, suas alegações finais orais foram gravadas pelo sistema Microsoft Teams e armazenadas no sistema SAJ junto com a prova oral colhida em audiência.

Na sequência, pelo(a) MM(a). Juiz(a), foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos.

I – RELATÓRIO

Trata-se da ação penal ajuizada pelo Ministério Público contra GABRIEL FIRMINO BRITO, qualificado. Narrou a denúncia que, no dia 19 de abril de 2022, por volta das 13h30min, na Rua José Pedro dos Santos, altura do nº 10, nesta comarca, o denunciado, agindo em concurso com o adolescente Jonatas Aparecido de Oliveira Carvalho, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 75 porções de cocaína, com peso aproximado de 121,51gramas; e 22 porções de Cannabis sativa L (maconha), com peso aproximado de 36,84gramas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pugnou, assim, pela condenação às sanções do art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

Notificado, em defesa prévia, sem preliminares, o acusado teceu alegações meritórias. Requereu a rejeição da denúncia e subsidiariamente a absolvição sumária. Não arrolou testemunhas (fls. 95/104).

Em "aditamento à denúncia" o increpado arrolou testemunhas (fls. 106/107).

A denúncia foi recebida em 08/06/2022, designando-se audiência de instrução (fl. 112).

Ao longo da instrução foram ouvidas 3 (três) testemunhas e interrogado o acusado. Gustavo Ferreira da Silva foi ouvido como testemunha do juízo. Rosana Ferreira teve seu depoimento dispensado, conforme decisão fundamentada exarada em audiência, ao passo que não se fez presente em duas oportunidades.

Na fase do art. 402 do CPP, nenhuma diligência foi requerida.

Por meio de alegações finais escritas, o Ministério Público reiterou os termos da inicial acusatória e requereu a condenação do acusado.

Por sua vez, a Defesa pleiteou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06, requereu a fixação da pena no mínimo legal, ressaltando sua primariedade, o reconhecimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Fundamento e decido.

II- FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidades a inquinar o feito, e estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, examino o mérito.

A materialidade dos fatos promana do auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 31/32), auto de exibição e apreensão (fls. 35/36), auto de constatação preliminar (fl. 38), laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 81/83), bem como a prova oral colhida.

A autoria é certa e deve ser atribuída ao acusado, a despeito de a ter negado em interrogatório.

A versão apresentada ficou isolada no conjunto probatório formado ao longo da persecução criminal.

Com efeito, o policial civil Cesar Augusto Seridonio, em juízo, ratificou o que disse na fase inquisitorial e aduziu que em razão de denúncias anônimas dando conta do tráfico de drogas no local dos fatos, praticado por dois elementos, sendo um de vulgo "Gabrielzinho" e o outro "Neguinho", dirigiram-se para o município de Santa Cruz das Palmeiras, onde foi montada uma vigilância velada com uso de viaturas descaracterizadas; foi possível visualizar tanto o autuado Gabriel como o adolescente infrator Jonatas servindo a usuários e inclusive o local onde estavam escondendo da droga, ou seja, no pneu de um ônibus que estava estacionado nas proximidades; não foi possível abordar usuários devido a distância da vigilância e para evitar que os traficantes conseguissem fugir, já que vendiam em via pública; em poder do adolescente Jonatas, foi localizada 02 (duas) porções de maconha e R\$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro, enquanto Gabriel nada trazia consigo; no local onde estavam escondendo a droga, foi encontrada uma pochete de cor preta e dentro desta diversas porções de cocaína e maconha, inclusive a maconha estava embalada de forma idêntica àquelas encontradas com o adolescente; ambos negaram a traficância e nenhum deles assumiu a propriedade da droga, alegando serem apenas usuários; em ato contínuo, se dirigiram a casa de Gabriel, naquele mesmo município, onde foi franqueada a entrada por ele mesmo e sua companheira que estava na casa e no guardo foi encontrado sobre a janela um eppendorfs contendo cocaína e duas porções de maconha, todas idênticas a já apreendidas, inclusive os eppendorfs são da mesma cor, ou seja, rosado; não aparentava o acusado e o adolescente estarem drogados; nenhum objeto para consumo foi achado; o local é palco conhecido de tráfico.

A testemunha Evaldo Armando Antonialli, também policial, sob o crivo do contraditório, corroborou o aduzido pelo colega de profissão, depondo em semelhante sentido.

Nada nos autos aponta no sentido de que os deponentes tiveram o intuito espúrio de incriminar o agente indevidamente, o que não decorre automaticamente da circunstância de se cuidar de policiais civis. Até porque prestaram depoimento sob o compromisso do art. 203 do CPP, razão pela qual o quanto por eles aduzido merece relevo para fins de formação do convencimento decisório. A jurisprudência é pacífica sobre o tema:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0/SP, Min. Celso de Mello, j. 18.2.97, apud JTJ 263/518)

Lado outro, a testemunha Gustavo Ferreira da Silva, amigo íntimo do réu, disse que estava com ele no dia em que foi preso, fumando um baseado; assim que ele desceu, as caminhonetes de bate pronto e o prenderam, cerca de 3 a 5 minutos; o denunciado não estava vendendo nada, pois tinha acabado de chegar; os policiais civis estavam em uma viatura; conhece Rosana, que mora perto do local dos fatos.

Seus informes, entretanto, não socorrem a Defesa. Afinal, trata-se de pessoa interessada em livrar o denunciado, em razão de íntima amizade, a qual, embora não figure no CPP como causa impeditiva do compromisso legal, torna seu relato pouco

crível e de nenhum valor probatório, sobretudo em se considerando que tal é impreciso e vago, como visto acima, demais de por completo dissonante dos ricos, detalhados, coerentes e firmes depoimentos dos milicianos.

As drogas não se destinavam ao exclusivo consumo pessoal. É o que deflui da análise em concreto dos parâmetros estabelecidos pelo art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Afinal, foram apreendidos entorpecentes de natureza diversa (maconha e cocaína) e de alto potencial ofensivo (cocaína), que estavam embalados para venda. Além disso, houve denúncia anônima de tráfico, o indivíduo não aparentava estar drogado como um mero usuário ali presente, até porque nenhum objeto para consumo foi achado, presenciou-se as transações a compradores e o local da ocorrência é palco frequente de tráfico. Tudo isso reflete o propósito de difusão ilícita, o qual não é excluído, por si só, pela eventual concomitante condição de usuário regular de drogas.

Bem por isso, ficou claro que o denunciado, de forma consciente e intencional e, portanto, dolosa (art. 18, I, CP), trouxe consigo e guardou drogas, com finalidade mercantil, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O fez juntamente com o adolescente Jonatas Aparecido de Oliveira Carvalho (fls. 31/32).

O fato, pois, é típico, por se amoldar à conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

A ilicitude é patente, à luz da teoria indiciária ou da ratio cognoscendi, porquanto não há quaisquer eximentes.

Também se faz presente a culpabilidade. Isso porque o réu é imputável, tinha potencial consciência da ilicitude e dele era exigível conduta diversa, nenhuma dirimente militando em seu favor.

Nesse cenário, observada a harmonia e a coesão do conjunto probatório, não há qualquer incongruência ou dúvida relevante que pudesse atrair a incidência do in dubio pro reo, corolário do princípio da presunção de inocência (art. 5º, XLVI, CF/88).

Destarte, sendo o fato típico, ilícito e culpável, de rigor a condenação.

II.1 – DOSIMETRIA DAS PENAS

Passo, pois, à dosimetria e individualização das penas (art. 5º, XLVI, CF/88), norteando-me, precipuamente, pelos arts. 59 e 68 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06.

A culpabilidade, assim entendido o grau de reprovabilidade assim entendido o grau de reprovabilidade, é normal à espécie. Bons antecedentes. A conduta social, caracterizada pelo comportamento no meio em que vive, a personalidade, que representa a índole do agente, e os motivos, consubstanciados pelas razões delitivas, não contam com elementos suficientes para esclarecimento. As circunstâncias, dados periféricos da prática criminosa, que abrangem a natureza e a quantidade das drogas, são desfavoráveis, ao passo que envolvem cocaína, droga de alto potencial ofensivo à saúde. As consequências, as quais correspondem ao mal causado pelo delito que transcende o resultado típico, não foram graves. O comportamento da vítima, toda a coletividade, é neutro e não o desfavorece.

Na primeira fase, valoradas negativamente 1 (uma) circunstância, fixo as penas-base em 6 (seis) de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes e presente a agravante do art. 61, II, “j”, CP (calamidade pública), elevo as reprimendas para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

O delito foi cometido em ocasião de estado de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo n. 6 do Congresso Nacional e Decreto n.º 64.879 do Estado de São Paulo, ambos em vigor desde 20.03.20, assim permanecendo até a presente data. Trata-se de circunstância objetiva, cuja incidência deve se dar em razão da maior vulnerabilidade da saúde pública que, nem mesmo assim, foi óbice para que o réu cometesse o delito. Não se pode olvidar que a presente causa de exasperação da pena não se justifica apenas na hipótese em que o agente se vale da calamidade para praticar o delito. Ora, tal tem lugar, outrossim, em razão da maior reprovabilidade do fato praticado em meio ao caos sanitário provocado pela COVID-19, em que os recursos e esforços estatais devem ser focados no combate à pandemia – e não na persecução penal de delinquentes – em prol da preservação da vida e da saúde da

população, bens jurídicos dos mais caros à proteção a ser conferida pelo Direito Penal. Nessa linha: TJSP; Apelação Criminal 1510850-88.2020.8.26.0050; Relator (a): Gilda Alves Barbosa Diodatti; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 03/02/2021.

Na terceira fase, inexistindo quaisquer minorantes e reconhecida a majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/06 (sua prática envolveu adolescente), elevo as penas em 1/6, concretizando-as em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

É descabida a aplicação do privilégio, porquanto não preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, embora se cuide de agente primário, e não integrante de organização criminosa, dedica-se a atividades criminosas.

Afinal, ostenta longo histórico infracional, com registros da prática de atos análogos aos crimes de tráfico de drogas, estupro e imposição de medida socioeducativa pela prática do ato infracional equiparado ao crime de roubo majorado (processo nº 0000623-46.2016.8.26.0538 - fls. 46/47).

Fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta a ausência de informações sobre a condição econômica do réu (art. 49, § 1º c/c art. 60, CP).

O regime inicial será o fechado, ante o patamar de pena corporal aplicado (art. 33, § 2º, "a", CP).

Inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP, por falta de informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do acusado, mas também os requisitos subjetivos indispensáveis à estipulação de regime diverso do ora imposto, cabendo-lhe pleitear o benefício que entende devido junto à Vara de Execução Criminal Competente.

Não é cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, em virtude da quantidade de aplicada (arts. 44 e 77, CP).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido constante da exordial, resolvendo o mérito, para CONDENAR o réu, GABRIEL FIRMINO BRITO, qualificado nos autos, com fulcro no art. 387 do CPP, pela prática do crime previsto no art. 33, caput c/c 40, VI, da Lei 11.343/06, da Lei 11.343/06, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

IV - DELIBERAÇÕES FINAIS

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano causado pelas infrações, na forma do art. 387, IV, do CPP, ao passo que não houve requerimento por parte do Ministério Público, o que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado (art. 5º, LV, CF/88).

Defiro o recurso em liberdade, pois desnecessária a segregação cautelar, tendo em vista que não sobreveio fato novo e que assim respondeu à ação penal até o presente momento, à luz dos arts. 282 c/c art. 312 c/c art. 313 c/c art. 387, §1º, do CPP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Eventual requerimento de gratuidade da justiça será analisado na fase de execução.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Instituto de Identificação, na forma da lei; b) oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art. 15, III, da CF/88 c/c art. 71 do Código Eleitoral; c) expeça-se guia de execução definitiva (art. 106, LEP); d) determino a destruição das amostras de drogas guardadas para contraprova, com certificação nos autos (art. 72, Lei 11.343/06); e) se o caso, determino o pagamento de honorários ao (à) patrono (a) dativo nomeado (a), em valor proporcional aos serviços prestados, a critério do órgão pagador (DPE/OAB), expedindo a serventia o necessário; f) oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Dispensado o registro (Provimento CG n. 27/2016). "

A sentença foi lida aos presentes que saíram devidamente intimados. O Ministério Público manifestou desejo de não recorrer. A(0) ré(u) e o(a)(s) Advogado(a)(s) de

Defesa manifestaram interesse em recorrer no prazo legal. Sendo assim, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito: "Aguarde-se o trânsito em julgado para Defesa.".

Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema e juntados aos autos no sistema SAJ. NADA MAIS, para constar lavrei o presente termo de audiência. Dispensada a assinatura das partes por se tratar de processo eletrônico. Eu THAUANN PINHEIRO SANTIAGO, Escrevente Técnico Judiciário, M373043, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA